

1500095-74.2021.8.26.0242

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e a redistribuição dos autos ao JECrim (fls. 220/226).

A Defesa Técnica do acusado, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado pela ausência de provas de autoria do delito de tráfico de drogas, além de argumentar que é o caso de aplicação do princípio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500095-74.2021.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500095-74.2021.8.26.0242

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CONRADO MACIEL FIOD

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra CONRADO MACIEL FIOD, qualificado nos autos (fl. 05/09), dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 33, caput, e §1º, inciso II, da Lei Federal n. 11.343/06.

O acusado foi preso em flagrante em 1º de fevereiro de 2021 (fls. 01/02) e, no dia seguinte, recebeu as benesses da liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares (fls. 56/59), o que foi devidamente cumprido (fls. 64/66).

O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento dos autos (fls. 120/129), todavia, o Juízo considerou improcedentes as razões invocadas pelo Parquet e os autos foram remetidos ao Procurador-Geral do Ministério Público, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal (fls. 130/131), que determinou a designação de outro Promotor de Justiça para oferecimento da denúncia (fls. 133/143).

A denúncia foi oferecida em 19 de julho de 2021 (fls. 148/150).

Notificado (fls. 165/166), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 155/160 e 161/164).

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), as fases dos §§ 4º e 5º do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 foram suprimidas, houve o recebimento da denúncia e foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 175/178).

A instrução foi realizada, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa e, em seguida, realizado o interrogatório do acusado (fls. 214/216 – mídias digitais).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou o acolhimento parcial da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, requerendo a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e a redistribuição dos autos ao JECrim (fls. 220/226).

A Defesa Técnica do acusado, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado pela ausência de provas de autoria do delito de tráfico de drogas, além de argumentar que é o caso de aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, além da devolução do aparelho celular e do chip apreendidos (fls. 230/238).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O réu CONRADO MACIEL FIOD foi denunciado porque, supostamente, no dia 1º de fevereiro de 2021, por volta das 11h05min, na Rua Antônio Boscaglia, n. 196, Jardim Nova Igarapava, nesta cidade e Comarca de Igarapava/SP, tinha em depósito e cultivava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 17 (dezesete) pés de maconha com altura variada entre 1,80m e 2,30m, 03 (três) mudas da erva em 02 (duas) garrafas do tipo PET, 01 (uma) planta em fase de secagem e 02 (duas) porções da mesma planta já seca e embalada em saquinhos plásticos transparentes.

Segundo a denúncia, após denúncia anônima de plantação irregular de maconha no local, policiais militares se dirigiram ao local e, já do lado de fora da casa, avistaram os pés de maconha no quintal, ao passo em que abordaram o acusado, que franqueou a entrada no imóvel, ocasião em que constataram os itens acima descritos.

Após regular instrução probatória, a pretensão acusatória merece ser acolhida em parte.

As provas produzidas em juízo não demonstraram com a necessária segurança a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

A testemunha de acusação Edilmar de Souto Magatão, policial militar, em juízo, disse que receberam denúncia anônima noticiando plantação de maconha em determinado terreno, ao que se deslocaram até o local e, por cima do muro, foi possível visualizar as plantas. Contou que solicitaram apoio de um policial para evitar possíveis fugas pela parte de trás do imóvel, que atravessava o quarteirão. Descreveu o imóvel como local murado e com portão tanto na frente quanto nos fundos, indicando que o local onde estava a plantação estava numa extremidade do terreno, com acesso livre a partir da casa. Afirmou que bateu no portão da residência e o acusado saiu, ao que “o policial do fundo visualizou que ele ajeitou uma faca na cintura, o policial gritou que ele estava com uma faca, nesse momento o CONRADO tentou entrar pra residência... correu deixando o portão aberto, logo na sequência ele foi abordado”, ocasião em que encontraram uma faca em sua cintura e perguntaram o que estava acontecendo, momento em que “ele disse que havia maconha dentro da casa e franqueou a vistoria do local pela equipe”. Contou que ele e seu parceiro realizaram buscas no imóvel e localizaram 17 pés de maconha com aproximadamente 2 metros de altura cada, 3 mudas pequenas de maconha, 2 porções de maconha embrulhadas (uma delas em cima da pia da cozinha e a outra do lado de fora, dando a impressão de que foram arremessadas), 1 pé de maconha em processo de “ressecamento” em uma espécie de “estufa”, além de realizarem a apreensão de uma faca e do celular do réu. Esclareceu que a denúncia informou apenas a plantação e não noticiou nada relativo a tráfico de drogas. Afirmou que o acusado é de Igarapava e que ele teria dito que, durante algum tempo, morou fora da cidade e

retornou alguns meses antes, acrescentando que morava sozinho. Disse, ainda, que o acusado declarou que estudou na internet e plantou as mudas de maconha e que tudo o que foi localizado era destinado a seu consumo, além de esclarecer que não foram encontrados petrechos. Esclareceu, ainda, tratar-se da primeira e única ocorrência envolvendo CONRADO que atendeu, não tendo conhecimento de outros fatos, e que não havia mais ninguém no imóvel. Esclareceu, por fim, que a reação do acusado limitou-se a tentar correr da guarnição policial e que a faca que estava em sua posse era uma faca de cozinha, comum, e, ainda, que a “estufa” era um cômodo pequeno e a planta estava pendurada de “ponta cabeça” (fls. 214/216 – mídia digital).

O policial militar Fernando Henrique Oliveira, também arrolado como testemunha de acusação, disse que receberam denúncia anônima referente à plantação de maconha e deslocaram-se até o local, onde visualizaram do lado externo uma boa quantidade de plantas de maconha. Afirmou que, com o apoio de outro policial, que ficou atrás do terreno, foram até a entrada do imóvel para chamar o morador. Narrou que, ato contínuo, quando o morador foi atendê-los, o policial responsável pela área dos fundos gritou que ele estava com uma faca em sua cintura, razão pela qual realizaram a abordagem, ao que o investigado tentou correr, sem sucesso, e confessou que possuía quantidade de maconha e a plantação era dele. Disse que averiguaram a residência, com autorização do proprietário, e constatarem mais plantas no local. Declarou que foi a única ocasião em que teve contato com o acusado, não tendo ciência de notícias anteriores relativas ao tráfico de drogas. Disse que o acusado informou que a droga era destinada a consumo próprio, mas não se recorda em detalhes o que foi encontrado. Esclareceu que o imóvel era cercado e o muro era bem baixo – sendo possível visualizar a plantação, que estava bem alta –, além do fato de existirem dois portões, um na frente e outro aos fundos, acrescentando que tratava-se de apenas um terreno. Informou que participou das buscas no imóvel, mas não lembrou-se de muitos detalhes, recordando-se que, atrás da casa, havia um cômodo no qual havia plantas de maconha “secando” (fls. 214/216 – mídia digital).

No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais militares em fase investigativa (fls. 03 e 04, respectivamente).

A testemunha de defesa Edinamar Aparecida Isete da Costa disse que tomou conhecimento dos fatos posteriormente, acrescentando que foi proprietária de uma loja vizinha à avó de CONRADO. Declarou que a família do acusado é de cidade bem distante, de cujo nome não se recorda, apontando que o acusado residiu por períodos nesta cidade, acrescentando que cursou faculdade e, depois, foi embora, retornando em seguida. Declarou que conhece o imóvel onde os fatos ocorreram e sabe que CONRADO residia no endereço, apontando que o tio do réu pediu ajuda para castração de duas cachorras que o acusado teria adotado, desconhecendo se ele morava sozinho ou com outras pessoas e esclarecendo que não chegou a visitar o imóvel, que fica bem afastada. Disse que conhece CONRADO desde 2001, quando comprou a loja de Cármen, tia dele, e o via sempre que visitava a cidade de Igarapava acompanhado da genitora. Disse desconhecer envolvimento de CONRADO com o tráfico de drogas, afirmando que ele possui inteligência acima do normal e fez mais de uma faculdade, acrescentando que ele tem dificuldades de socialização e sempre foi muito sozinho, apontando que nunca o viu envolvido em confusão. Esclareceu que o acusado vive e se veste de forma simples, mora em imóvel herdado e ouviu de terceiros que a moto em que ele anda foi dada por seu irmão, apontando que nunca o vê em lugar algum, apenas na casa do tio em raras ocasiões. Disse desconhecer se o acusado faz uso de entorpecentes, mas chegou a suspeitar por suas atitudes (fls. 214/216 – mídia digital).

A testemunha de defesa Bráulio Raphael Nogueira Colmanetti disse que não presenciou os fatos e tomou conhecimento por meio de terceiros. Disse que conhece o acusado há cerca de 20 anos, entre as idas e vindas de CONRADO à Igarapava, onde trabalhou como dentista e na “Stop Car”. Afirmou que foi uma vez ao imóvel fazer entrega de suplementos, mas permaneceu na porta, acrescentando que não tem conhecimento do envolvimento do acusado com tráfico de drogas e que tomou ciência do consumo de drogas a partir dos presentes fatos. Declarou ter conhecimento de que CONRADO já morou em Santa Catarina por algum tempo, mas desconhece motivo específico pelo qual

voltou para Igarapava. Afirmou que conversam sobre academia e treinos físicos, apontando que o acusado é sozinho, vive “bem na dele” e possui poucos amigos. Declarou que o acusado é bem “fechado” e acredita que obtém seu sustento através de seus pais e irmão (fls. 214/216 – mídia digital).

O réu CONRADO MACIEL FIOD, por sua vez, em seu interrogatório judicial, disse que trabalha com próteses odontológicas de forma avulsa e auferir renda mensal de 1,5 salários mínimos, apontando que ainda reside sozinho no mesmo imóvel. Esclareceu que retornou para Igarapava há cerca de 2 anos e, antes disso, estava residindo em Florianópolis/SC. Sobre os fatos em apuração, confessou o plantio dos pés de maconha em seu imóvel, realizado apenas por ele, cerca de 5 meses antes dos fatos (fevereiro de 2021), apontando que estava aguardando a floração e não tinha realizado nenhuma colheita. Afirmou que realizou o plantio pois “eu não queria gastar mais o dinheiro com tráfico porque me faz falta final do mês”, esclarecendo que faz uso apenas de maconha desde seus 16 anos. Perguntado, disse que “Anderson” é amigo da família e vizinho de seu irmão em Florianópolis/SC, mas não se recorda de conversa travada com ele em janeiro de 2021, na qual menciona “Olha só, meu irmão precisa de grana, arruma a cozinha direito aí viu?” (fls. 108), disse que não se recorda do diálogo e, por isso, acredita que não seja nada importante, apontando que “Anderson” era inquilino de uma quitenete que tinha banheiro e cozinha em comum com outros locatários de quartos e havia uma reclamação referente à cozinha suja por parte de “Anderson”. Questionado sobre o prosseguimento da conversa, quando diz “Olha nego, vc colabora aí porque ele ainda tá pagando a prestação da minha moto hein... ABRAÇO” (fls. 108), afirmou que seu irmão lhe deu uma moto e acabou de pagá-la no ano passado e, perguntado a respeito da fotografia de pés de maconha enviada para o interlocutor (fls. 108/109) e dizeres “Esqueci de mostrar olha a minha plantação de maconha” (fls. 109), recorda-se do diálogo, afirmando que acredita que também mandou a foto para seu irmão, “pra fazer graça”. Negou que tenha efetuado a comercialização ou fornecimento de drogas para terceiros, afirmando que toda a plantação era destinada a ele e estava esperando a floração, pois “só as flores que me interessava”, dizendo que aprendeu a cuidar da plantação porque “faz 30 anos que eu assisto Globo Rural”, onde ensinam a plantar, adubar e proteger o solo, acrescentando que possui diversas outras frutas no quintal. Questionado acerca da “secagem” da maconha, disse que pensou em extrair o óleo, além de afirmar que a plantação foi uma “fileira” e que as mudas foram preparadas a partir das sementes que separou das impurezas do produto adquirido. Esclareceu que teve problemas com vizinho em Florianópolis/SC em razão de excesso de barulhos do cachorro do vizinho, razão pela qual firmou acordo e veio para Igarapava logo em seguida, porque gosta do clima do cerrado. Afirmou que seu pai deixa a renda do aluguel de um apartamento para ele, o que acrescenta cerca de 1 salário mínimo mensal à sua renda (fls. 214/216 – mídia digital).

Apesar da localização e apreensão/destruição de 2 (duas) porções de maconha, 1 (uma) planta em processo de ressecamento, 3 (três) mudas e 17 (dezessete) plantas, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 24), laudos periciais realizados nos entorpecentes (fls. 26/37 e 96/98), bem como laudo pericial realizado no local (fls. 85/95) e fotografias do imóvel (fls. 19/23), não ficou cabalmente comprovado que os entorpecentes seriam destinados à traficância, especialmente porque nenhum dos policiais visualizou ou indicou movimentos relacionados à mercancia de drogas pelo réu, desconhecido dos meios policiais.

Neste ponto, ressalto que, conforme narrado pelas testemunhas de acusação em juízo, a própria denúncia anônima noticiou apenas a plantação de maconha, que, segundo consta, era realmente visível do lado externo do imóvel, sem apontar outros elementos aptos a indicar a traficância.

Para além disso, a análise pericial realizada no aparelho celular do acusado (fls. 99/113) não apontou elementos confirmatórios da narcotraficância.

Apenas a conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp com “Anderson”, em 09 de janeiro de 2021, em que o acusado envia fotografia das plantas de maconha e diz “olha a minha plantação de maconha” (fls. 106/111). Em verdade, a imagem enviada teria sido capturada no mesmo local dos fatos em 18 de dezembro de 2020 (fls. 112), mostrando-se condizente, portanto, com o tempo necessário para cultivo do

entorpecente.

Acrescento, ainda, que a ausência de petrechos ou outros itens relacionados à traficância também indica que o réu não comercializava drogas.

Além disso, o acusado não ostenta registros criminais aptos a ensejar a apontar dedicação habitual à traficância, seja no Estado de São Paulo (fls. 239/240 e 241/242), seja no Estado de Santa Catarina, onde residia anteriormente (vide fls. 187/192) – não ignorada a transação firmada nos autos n. 0003539-

88.2019.8.24.0090<https://eprocwebcon.tjsc.jus.br/consulta1g/>

externo_controlador.php?

acao=processo_seleciona_publica#_processo=00035398820198240090&eventos=true#_chave=#_chave_documento=&hash=0620ec8bbf1f5cb8f042f7beb2cd06ac perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Universidade Federal de Santa Catarina (vide fls. 189).

Neste sentido, a versão do réu de que a plantação destinava-se a consumo próprio possui coerência com os elementos dos autos e coloca dúvida acerca da efetiva destinação dos entorpecentes encontrados em sua residência.

Assim, tais circunstâncias, aliadas aos demais elementos dos autos não são capazes de demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o acusado praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06.

Ou seja, os indícios que autorizaram o recebimento da denúncia não se confirmaram em provas concludentes para a condenação do réu por este delito.

Portanto, diante da fragilidade probatória e, havendo dúvida se os entorpecentes seriam destinados ao narcotráfico, a conclusão deve ser aquela mais favorável ao réu.

Assim sendo, a conduta praticada pelo acusado CONRADO deve ser desclassificada para o crime previsto no artigo 28 da Lei Federal n. 11.343/2006, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“Apreendida pequena quantidade de tóxicos e alegando o réu posse da substância proibida apenas para uso próprio, inexistindo prova de tráfico, impõe-se a condenação do acusado tão somente como usuário.”

Tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à Defesa, motivo pelo qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, eis que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inicial. Neste sentido, STJ, HC 49416/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 01.06.06, DJ de 01.08.06.

Nesse contexto, com o deslinde da instrução, razoável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes.

Ao contrário do que sustenta a Defesa, é inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, vez que a pequena quantidade de droga é própria da natureza do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Nestes termos, ensina Guilherme de Souza Nucci: “Difere este crime do previsto no art. 33, justamente em face da finalidade específica do agente (consumo pessoal). Não se trata de infração de menor potencial ofensivo, mas de ínfimo potencial ofensivo (...) Denominamos de ínfimo potencial ofensivo o crime previsto no art. 28 desta Lei, tendo em vista que, mesmo não sendo possível a transação, ainda que reincidente o agente, com maus antecedentes ou péssima conduta social, jamais será aplicada pena privativa de liberdade”.

Nesse sentido:

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância, por ser a posse de entorpecentes para uso crime de perigo abstrato, aliás, a pequena quantidade de estupefaciente é justamente o que a caracteriza, porque a diferencia do tráfico.

Condenação mantida. PENA. Estabelecida a reprimenda de prestação de serviços à comunidade, pelo período de dez meses, dada a dupla reincidência do acusado.

Manutenção. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1546278-89.2016.8.26.0562;

Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019) – grifei.

Apelação Criminal – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – Materialidade e autoria

devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Oitiva de testemunhas – Conduta típica não alcançada pela bagatela penal. Necessidade de proteção do bem jurídico saúde pública – Inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas. Inocorrência. Dispositivo, em tese, constitucional. Questão a ser decidida pela e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – Reprimenda. Adequação – Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1534108-17.2018.8.26.0562; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022) – grifei. Ademais, o próprio réu confessou que os entorpecentes destinavam-se ao uso (fls. 214/216 – mídia digital), de tal modo que não há que se falar em absolvição por falta de provas.

Oportuno salientar que não se ignora o diagnóstico médico relativo ao acusado (fls. 164), aparentemente condizente com as informações relativas ao seu histórico de vida e social constantes nos autos que, todavia, não tem o condão de eximi-lo da responsabilidade penal, eis que capaz de entender o caráter ilícito do fato (artigo 26, caput, do Código Penal).

Assim, impõe-se a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 28, da Lei de n. 11.343/06.

Reconhecida, portanto, a ocorrência do delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 em relação ao réu e a responsabilidade deste, passo à fixação da pena: Na dosimetria da pena, atendendo às circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, bem como do artigo 59, do Código Penal, fixo ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/2006. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão acusatória para DESCLASSIFICAR a imputação originária de tráfico para a de posse ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal e, desta forma, CONDENAR o acusado CONRADO MACIEL FIOD nas penas do crime do artigo 28, caput, da Lei Federal n. 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada nos termos do convênio Defensoria Pública/SP e OAB/SP (fls. 44), consignando sua atuação parcial ante a constituição de defensor pelo acusado (fls. 73).

Nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, defiro a restituição do aparelho celular Xiaomi Redmi Note 7 IMEIs 861596041682134 e 861596042242136 ao acusado.

Se ainda pendente, determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 72 da Lei Federal n. 11.343/06.

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 17 de outubro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)